

1500872-82.2020.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/04/2022

... para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

Não diverge o STJ (sem grifos no original).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Esta Corte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Dr. Carlando Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

1500872-82.2020.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500872-82.2020.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA APARECIDA GIANEZI DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Vistos.

A Constituição garante a intimidade de todos, bem como o direito à livre locomoção (incisos X e XV do art. 5º da Constituição).

As forças policiais tem o dever constitucional de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144).

Para tanto, em razão do princípio da legalidade (art. 37 da Constituição), devem atuar nos exatos limites estabelecidos pela lei (desde que esta não viole as normas constitucionais).

Os policiais militares, responsáveis pelo policiamento ostensivo (§5º do art. 144 da Constituição), podem mitigar a intimidade e a liberdade de locomoção dos cidadãos sempre que estiverem diante de "fundadas suspeitas" (§2º do art. 240 do Código de Processo Penal).

No caso, os policiais militares apontaram como justificativa para a busca pessoal uma denúncia anônima.

No entanto, o STJ, tribunal responsável pela uniformização da aplicação do direito processual penal no Brasil (art. 22, inciso I, c.c. art. 105, inciso III, ambos da Constituição), tem entendido que denúncias anônimas e apresentação de nervosismo

por parte do investigado não constituem “fundadas suspeitas” a ponto de legitimar a diligência invasiva.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.

2. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal.

3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes. HC 625819/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021, DJE 26/02/2021.

Obviamente, o encontro posterior do bem de origem ilícita não torna válida a diligência.

É sempre bom lembrar a decisão do STF por ocasião do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, publicado em 10/05/2016) quando, em matéria absolutamente análoga (busca domiciliar sem mandado judicial), decidiu que não será a constatação de situação de flagrância, posterior à diligência, que justificará a medida, devendo os agentes estatais demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (em nosso caso, “suspeitas”) para a medida.

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)

para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

Não diverge o STJ (sem grifos no original).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio.

2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no "nervosismo" apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal.

4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

HC 659689/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021.

É de se ressaltar, por fim, que os policiais tinham a informação do trajeto realizado pela pessoa imputada, sendo possível, p. ex., um acompanhamento até o suposto local da compra, diligência esta que teria o condão de configurar, nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, justa causa para a diligência invasiva.

Ressalto também que o voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, na apreciação do citado Tema 280 (análogo ao caso), expressamente rechaça denúncias anônimas e informações de inteligência policial como justa causa para diligências invasivas:

Por outro lado, provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de “informantes policiais” (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa.

Incide, assim, a vedação constitucional do inciso LVI do art. 5º:

são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos

Não havendo nos autos provas independentes a comprovar a legitimidade da acusação (§1º do art. 157 do Código de Processo Penal), é o caso de absolver a pessoa acusada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER MARIA APARECIDA GIANEZI DOS SANTOS das acusações a ela imputadas na denúncia nos termos do inciso II do art. 386 do Código de Processo Penal.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA